

<제05장 취소소송의 심리.제03절 처분사유의 추가·변경>

[기출][2021-3]취소소송 계속 중 피고 행정청이 당초 징계사유 외에 다른 징계사유를 추가적으로 주장할 수 있는지 여부

《[문제3] 국가공무원 甲은 업무시간 중 민원인으로부터 골프접대 등의 뇌물을 수수하였다는 이유로 징계권자로부터 해임의 징계처분을 받고, 그 징계처분에 대하여 소청심사를 거쳐 취소소송을 제기하였다. 피고 행정청은 취소소송의 계속 중 甲이 뇌물수수뿐만 아니라 업무시간 중 골프접대를 받는 등 직무를 태만히 한 것도 징계사유의 하나라고 소송절차에서 주장하였다. 이러한 피고의 주장이 허용되는지 설명하시오. (25점)》

「국가공무원법 제78조(징계 사유)」

❶ 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 징계 의결을 요구하여야 하고 그 징계 의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다.

1. 이 법 및 이 법에 따른 명령을 위반한 경우
2. 직무상의 의무(다른 법령에서 공무원의 신분으로 인하여 부과된 의무를 포함한다)를 위반하거나 직무를 태만히 한 때
3. 직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때

<문제3> 취소소송 계속 중 피고 행정청이 당초 징계사유 외에 다른 징계사유를 추가적으로 주장할 수 있는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 국가공무원 甲은 뇌물수수를 이유로 해임처분을 받고 취소소송을 제기하였는데, 소송 계속 중 피고 행정청은 당초 처분사유 외에 업무시간 중 골프접대를 받는 등 직무태만 행위도 징계사유에 해당한다고 추가 주장하고 있다. 쟁점으로 <취소소송에서 처분청이 당초 처분 당시 제시하지 않은 새로운 징계사유를 추가하여 주장하는 것이 처분사유의 추가·변경으로서 허용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 피고 행정청의 새로운 징계사유 주장 허용 여부에 대하여 설명한다.

II. 처분사유의 추가·변경과 재량행위의 법리

1. 처분사유의 추가·변경의 의의 및 필요성

(1) 개념 및 의의

- 처분사유의 추가·변경이란 행정청이 소송 계속 중에 처분의 적법성을 유지하기 위해 처분 당시 제시했던 사유 외에 다른 사유를 추가하거나 변경하여 주장하는 소송법상 행위를 말한다.

(2) 인정의 필요성

- 행정소송법상 명문 규정은 없으나 법원은 분쟁의 일회적 해결을 통한 소송경제 도모와 반복 소송의 방지를 위해 제한적인 범위 내에서 처분사유의 추가·변경을 인정하고 있다.

2. 처분사유의 추가·변경의 허용 한계

(1) 기본적 사실관계의 동일성

- 추가되는 사유는 당초 처분사유와 기본적 사실관계에서 동일성이 유지되어야 한다. 동일성 여부는 시간적·장소적 근접성, 행위의 태양, 침해 법익 등을 종합하여 사회적 사실관계가 객관적으로 동일한지에 따라 판단한다.

(2) 시간적 및 절차적 한계

- 처분사유의 추가·변경은 처분 당시에 이미 존재했던 객관적 사실에 한하여 허용되며(시간적 한계), 원고의 실질적 방어권을 침해하지 않는 범위 내에서 허용되어야 한다(절차적 한계).

3. 재량행위와 처분사유의 추가·변경

(1) 허용 여부에 관한 학설

- 재량행위의 경우 처분사유를 변경하면 재량권 행사의 기초가 바뀌어 법원의 재량심사 구도가 변하므로 허용할 수 없다는 부정설과, 기속행위와 마찬가지로 일정한 범위 내에서 인정해야 한다는 제한적 긍정설이 대립한다.

(2) 판례의 태도

- “대법원”은 처분의 성격이 기속행위인지 재량행위인지 여부를 불문하고, 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 범위 내에서는 처분사유의 추가·변경을 허용한다는 일관된 입장을 취하고 있다.

III. 사안의 적용

1. 재량행위인 징계처분에서의 적용 가능성

(1) 징계처분의 성격

- 공무원에 대한 해임처분 등 징계처분은 관계 법령상 행정청의 광범위한 재량이 인정되는 재량행위에 해당한다.

(2) 판례에 따른 처분사유의 추가·변경의 허용

- 재량행위인 공무원 징계처분이라 하더라도 “판례”에 의할 때 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 한 처분사유의 추가·변경 자체는 가능하다.

2. 기본적 사실관계의 동일성 여부 판단

(1) 당초 사유와 추가 사유의 성격 분석

- 당초의 징계사유는 뇌물수수로 국가공무원법상 청렴의무 위반에 해당하며, 추가하려는 사유는 직무태만으로 성실의무 위반에 해당한다.

(2) 동일성 부정에 따른 불허

- 두 사유는 근무시간 중에 발생한 골프행위라는 점에서 시간적·장소적 밀접성이 있어 보이나, 의무 위반의 구체적 내용과 침해 법익이 상이하다. 뇌물수수는 직무의 청렴성을 해치는 비위이고, 직무태만은 직무 수행의 성실성을 저해하는 행위로 그 기초가 되는 사회적 사실관계가 객관적으로 동일하다고 보기 어렵다. 따라서 두 사유 간의 기본적 사실관계의 동일성은 부정된다.

IV. 결론

- 취소소송 중 피고 행정청의 처분사유의 추가·변경 주장은 당초의 사유와 추가하려는 사유 사이에 기본적 사실관계의 동일성이 존재해야만 허용된다. 사안의 해임처분은 재량행위이므로 처분사유의 추가·변경을 허용함에 있어 원고의 방어권 보장이 더욱 엄격하게 요구된다. 피고 행정청이 추가로 주장하는 직무태만의 사유는 당초 징계사유인 뇌물수수와 의무 위반의 취지 및 객관적 사실 내용이 완전히 다른 별개의 징계사유에 해당한다. 따라서 양 사유 간에는 기본적 사실관계의 동일성이 인정되지 않으므로, 법원은 피고 행정청의 추가 주장을 허용해서는 안 되며 당초의 뇌물수수 사유만을 기준으로 해임처분의 적법 여부를 심리하여야 한다.